

0000082-17.2019.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA GOMES

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2360/2019 - Delegacia de Polícia de Arujá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARINE LAIZE DE OLIVEIRA GRACIANO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA GOMES

A) RELATÓRIO

CARINE LAIZE DE OLIVEIRA GRACIANO, GUILHERME MALAFAIA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

2ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja-SP - cep 07401-125

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0000082-17.2019.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000082-17.2019.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2360/2019 - Delegacia de Polícia de Arujá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARINE LAIZE DE OLIVEIRA GRACIANO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA GOMES

A) RELATÓRIO

CARINE LAIZE DE OLIVEIRA GRACIANO, GUILHERME MALAFAIA CUNHA, EDUARDO RIBEIRO DOS

SANTOS e PRISCILLA MAIA CORREA DA SILVA, qualificado nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, "no dia 22 de junho de 2019, por volta das 23h30min, de local incerto até a Rodovia Presidente Dutra (BR 116), km 204 + 500 Jardim Emília, nesta cidade de Arujá/SP, EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS, GUILHERME MALAFAIA CUNHA, CARINE LAIZE DE OLIVEIRA GRACIANO e PRISCILLA MAIA CORREA DA SILVA, agindo em concurso e unidade de propósitos, transportavam e guardavam drogas, com o fim de entregar a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, consistentes em 89 (oitenta e nove) micropontos de Metilenodioximetanfetamina (MDMA), com peso aproximado de 12g (doze gramas), 24 (vinte e quatro) comprimidos de Dietilamida do ácido lisérgico (LSD), com peso aproximado de 1.4g (um grama e quarenta decigramas), e 01 (um) frasco contendo 0.5 mililitros de Dietilamida do ácido lisérgico (LSD), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls. 215 e laudo de constatação provisória a fls. 219/222)".

Após a prisão em flagrante foi concedida liberdade provisória com imposição de medidas cautelares (fls. 100/103).

Foram notificados e apresentaram defesas prévias. Recebida a denúncia, realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e os réus interrogados.

Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu o acolhimento dos pedidos, nos termos da denúncia. Em síntese, a defesa requereu a absolvição, sustentando que as provas são precárias.

B) ANÁLISE DO CASO CONCRETO

Imputa-se a prática do seguinte crime da Lei 11.343/06:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas".

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

O fato existiu. A materialidade está comprovada pela prova oral produzida; boletim de ocorrência (fls. 17/20); auto de exibição e apreensão (fls. 31/32); laudo de constatação provisório (fls. 36/39) e laudo pericial definitivo (fls. 194/197), que atestam que as substâncias encontradas eram de uso proibido pela Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 (89 micropontos de LSD; 24 comprimidos de MDMA - Ecstasy; e 1 frasco com 0,5ml de LSD).

A testemunha Fred Henrique dos Santos disse em Juízo que sua equipe abordou o veículo onde estavam os réus, e no interior da carteira do condutor foi encontrado LSD e Ecstasy. Fora do interior da carteira do condutor havia um LCD líquido, estava dentro do veículo. O condutor disse que ele, sua namorada e o outro casal iriam para o "Rave" em Tremembé e todos iriam fazer uso da droga. Não se recorda o que os demais falaram. Não se recorda de quantia em dinheiro. Na carteira de Eduardo, onde estavam as drogas, haviam seus documentos pessoais.

A testemunha River Rosa Sobires disse em Juízo que estava em fiscalização de rotina no pedágio de Arujá, ao avistar o veículo percebeu que demonstraram nervosismo, motivo pelo qual decidiu abordar o veículo. Na carteira do motorista encontrou LSD, Ecstasy e LCD líquido. Ele disse que os quatro iriam consumir a droga na "Rave", o que foi admitido pelos quatro. Não se recorda de detalhes sobre onde a droga iriam

comprar a droga. O LSD líquido não estaria na carteira, mas o LCD microtubo e Ecstasy sim. Nenhum outro material ilícito foi encontrado.

O réu Eduardo Ribeiro dos Santos disse em interrogatório perante o Juízo, em síntese, que Priscilla era sua namorada, hoje são casados. Eram amigos de Carine e Guilherme. O depoente estava dirigindo. Foram abordados e os policiais encontraram as drogas dentro de sua carteira. Guilherme era proprietário do veículo, mas ele consumiu bebidas alcóolicas, então o depoente dirigiu. O depoente foi buscado por Guilherme em uma estação de trem. Iriam há uma festa "Rave". As drogas encontradas eram de propriedade do depoente. Comprou por aproximadamente 500 reais, um colega de academia indicou. Comprou a droga no dia da festa, no metro República. Seu objetivo era comprar a droga e guardar em casa, mas não teve tempo. Consumia droga todo final de semana, motivo pelo qual comprou maior quantidade. Os outros ocupantes do veículo não sabiam que tinha a droga. Não leu seu depoimento na delegacia. Consumia tais drogas há 6 meses aproximadamente. Nas festas comprava drogas por unidade, pagava mais caro. Ao comprar em maior quantidade, gastou a metade. Priscilla sabia que era usuário, mas não consumia.

O réu Guilherme Malaфаia Cunha disse em interrogatório perante o Juízo, em síntese, que é namorado de Camile, conhece Eduardo e Priscila de festas. Foram abordados no pedágio, Eduardo estava dirigindo seu carro. Os policiais informaram que localizaram drogas com Eduardo. Não sabe que Eduardo estava com as drogas. Não combinou com o Eduardo de comprar as drogas. O depoente não consome drogas, apenas bebida alcoólica. Não sabia se Eduardo vendia drogas nas festas "Rave". Nunca viu Eduardo consumindo drogas. Um policial na delegacia disse que a melhor forma de sair dali seria se todos "dividissem" tudo, com o que não concordou. Teve um "bate papo" no saguão, não prestou depoimento sozinho. Não leu o papel que assinou. Recebeu o papel pela manhã, os policiais entregaram dizendo que tinha que assinar. Não são corretas as informações que constam naquele depoimento, não teve conversa com Eduardo sobre fornecimento de drogas. Não é usuário de drogas. Eduardo nunca ofereceu droga ao depoente. Eduardo pediu carona no mesmo dia da festa. Ele seria levado por outra pessoa, Otávio. Eduardo assumiu a direção do veículo após pararem no posto, pois o depoente tomou uma cerveja.

A ré Carine Laize de Oliveira Graciano disse em interrogatório perante o Juízo, em síntese, que Guilherme é seu namorado, Priscila e Eduardo conhece de amigos comuns de festas. Não é usuária de drogas, Guilherme também não. Nunca viu Eduardo e Priscila usando droga. Tinha um grupo de amigos de Whatsapp para dividir carona para as festas. Saíram de casa, pegaram Eduardo e Priscila. Priscila na casa dela, e Eduardo na estação do Jaraguá. Pararam em um posto de gasolina e compraram cerveja, motivo pelo qual Eduardo seguiu dirigindo. Não sabia que Eduardo estava com droga. Ele não ofereceu droga ao depoente. Não prestou declarações na delegacia, apenas um policial perguntou se usava droga, se tinha comprado. Um policial pediu para assinar um papel, estava bravo, e o depoente assinou sem ler. Em momento algum na delegacia afirmou que tinha ciência que Eduardo estava com droga. Priscila e Eduardo iriam de carona com Otávio, mas isso foi alterado.

A ré Priscilla Maia Correa da Silva disse em interrogatório perante o Juízo que conhece os outros réus Carine e Guilherme de festas. Namorava Eduardo há 6 anos. Gostava de músicas eletrônicas, mas nunca usou drogas. Chegou a brigar com Eduardo quando soube que ele havia consumir droga em uma festa. No dia dos fatos, não sabia que Eduardo estava levando droga no carro. Nunca viu Carine e Guilherme usarem drogas. Não prestou depoimento na polícia como constou no termo. Na Delegacia, ficaram os quatro no saguão, depois ficaram os 4 juntos em uma cela. Ninguém conversou reservadamente com algum servidor da polícia ou delegado. Pediram para assinar um papel, o depoente não leu pois estava muito nervosa. Não informaram que era o depoimento. Nunca viu Eduardo fornecendo drogas para outras pessoas, nem para o depoente.

A testemunha de defesa Otávio Moraes Conde Siqueira disse em Juízo que é amigo de Guilherme, da faculdade. Não estava presente quando os réus foram detidos. Foram distribuídos grupos de carro para ir para a festa. A princípio o depoente iria dar carona para Eduardo, Priscila e Brena. Mas por questão de logística, a proximidade entre Guilherme e Eduardo, isso foi alterado. Pelo que sabe, Guilherme e Carine não

usam drogas. Eduardo e Priscila são amigos de uma conhecida de sua faculdade. Não sabe se eles usam drogas. O depoente também foi para a festa "Rave". Foram ouvidas ainda outras testemunhas de defesa.

A acusação logrou êxito em provar a prática de tráfico de drogas apenas por Eduardo.

Para os demais réus, Priscilla, Guilherme e Camile, não há qualquer prova produzida sob contraditório que indicasse também fossem os proprietários da droga, que, frise-se, foi apreendida exclusivamente na posse de Eduardo, conforme bem destacado pelos policiais. Aliás, as drogas estavam na própria carteira de Eduardo, objeto de inegável natureza pessoal e que conseguia ocultar completamente a droga dos demais ocupantes do veículo.

Acolher a pretensão acusatória em relação aos outros três réus dependeria que fosse estabelecida uma presunção: pelo simples fato de estarem no veículo estariam partilhando do suposto objetivo de Eduardo de vender ou distribuir as drogas para terceiros na festa. Contudo, o direito penal não contempla responsabilização objetiva, e não há qualquer elemento de prova colhido sob contraditório corroborando essa assertiva.

Para Guilherme e Carine existe ainda o reforço de que não seriam eles os responsáveis por dar carona para Eduardo e Priscila no dia, e sim Otávio, que ouvido na condição de testemunha confirmou essa versão.

Se as drogas pertenciam a Eduardo, é irrelevante saber se Priscilla, Guilherme e Camile eram usuários ou não, pois na pior das hipóteses estariam no veículo na condição de futuros e potenciais usuários.

O único elemento que fornece algum suporte à acusação é o interrogatório de Priscilla em solo policial, no qual disse que "conversaram no grupo e decidiram comprar as drogas para consumirem na festa" (fls. 13). Ocorre que tal versão não foi corroborada pelo depoimento prestado em Juízo sob contraditório, impedindo que a sentença condenatória se baseasse de maneira decisiva no relato anterior (art. 155, CPP).

Aliás, fosse verdade o que Priscilla disse em solo policial, não seria possível descartar que o crime praticado por todos seria o de posse de drogas para consumo pessoal, pois nesse caso a droga pertenceria a todos - e não apenas a Eduardo - e seria factível o consumo coletivo em razão da quantidade. Mas tal afirmação é feita a título de reforço argumentativo, pois, como dito, apenas o interrogatório produzido sob contraditório pode ser considerado.

Em relação a Eduardo, que confessou em Juízo que a droga lhe pertencia, lembre-se que o tráfico de drogas não se consuma apenas com o ato típico de "venda". Se o acusado pratica qualquer uma das 18 condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/06 terá incorrido no crime, inclusive na hipótese de apenas "ter em depósito", "guardar" ou "trazer consigo" a droga.

Mesmo a conduta de "oferecer" não exige a finalidade lucrativa, pois a lei tipifica as condutas praticadas "ainda que gratuitamente". Na realidade, o intuito de lucro é apenas uma circunstância negativa que justifica aumento da pena. Por isso, não se exige um elemento subjetivo especial, ou seja, a demonstração da intenção específica de praticar atos de mercancia. Basta o dolo genérico, a consciência e vontade de realizar alguma das ações que configuram o crime e dispensam intenção de venda.

O elemento subjetivo é determinante apenas para se descartar a hipótese de porte ou guarda da droga para uso pessoal, o que ensejaria a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Segundo o §2º deste dispositivo, "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No contexto dos autos, a quantidade era expressiva e incompatível com o objetivo de consumo pessoal. Eventualmente Eduardo até poderia não vender a droga com o intuito de lucro, mas é evidente que na pior das hipóteses iria fornecer parte da droga para outras pessoas consumirem na festa, o que também configura o crime, como visto acima.

O réu se defendeu alegando que teria adquirido uma grande quantidade para usar em outras oportunidades e que seu objetivo seria guardar em casa, mas não conseguiu. Contudo, não apresentou qualquer prova que corroborasse tal assertiva, ônus que lhe competia.

Merece destaque o depoimento da sua então namorada e hoje companheira Priscilla de que teria visualizado Eduardo consumindo droga uma única vez, ou seja, segundo sua própria namorada não era um usuário contumaz. Logo, não é verossímil que toda aquela droga adquirida seria para seu consumo pessoal.

De uma forma ou de outra, o réu foi abordado com expressiva quantidade de droga que não seria capaz de consumir, em direção a festa em que tipicamente referidos entorpecentes são utilizados de maneira indiscriminada, na companhia de pessoas que se dizem não usuários. A única conclusão logicamente possível é que a parte da droga seria destinada a terceiros naquela festa, estando bem demonstrado o objetivo da traficância.

Por fim, o simples fato de eventualmente ser usuário não afasta a configuração do tráfico, já que esses elementos não são excludentes.

A prova é coesa e harmônica no sentido de que o réu conscientemente praticou o delito, realizando todos os elementos da norma incriminadora. Há tipicidade formal e material. Sua conduta foi contrária ao direito, era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude de seus atos e lhe era exigível comportamento diverso. A condenação é medida que se impõe.

C) DOSIMETRIA

O Juiz deve concretizar a individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) analisando as particularidades da infração e condições pessoais do réu, buscando uma pena "suficiente para repressão e prevenção" (art. 59, CP).

O objetivo é fixar uma pena justa para a situação concreta, diferenciando-a das inúmeras outras em que o mesmo crime poderia ser cometido, por diversas pessoas e seus motivos, diferentes formas de execução, consequências individuais e coletivas. Na primeira etapa, as frações de aumento devem incidir preferencialmente sobre o intervalo abstrato entre a pena mínima e a máxima. Esse critério é mais adequado especialmente em crimes nos quais a distância entre as penas mínimas e máximas é expressiva, tal como no tráfico de drogas, cuja pena varia de 5 a 15 anos de reclusão. Se aplicada a fração de aumento sobre a pena mínima, a reprimenda nunca iria superar 10 anos de reclusão na primeira fase, mesmo em casos graves (aumento de 8/8). Isso deixaria de considerar toda a margem de variação prevista pelo legislador e tornaria a pena injusta.

Assim, "embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos" (grifei).

Nos crimes da Lei 11.343/06 merecem destaque ainda "a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente" (art. 42). O réu é primário.

A natureza e a quantidade de drogas autorizam o aumento da pena base, acarretando igualmente maiores transtornos sociais e esforços do Poder Público em combatê-los. Contudo, tais elementos serão levados em consideração apenas na modulação do grau de redução na terceira fase, sem prejuízo da repercussão dessas circunstâncias negativas no regime inicial e demais benefícios.

Fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não incidem agravantes ou atenuantes.

Sendo o réu primário e inexistente outra ação penal em curso, viável a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei 11.343/06).

Contudo, a redução é feita no patamar mínimo (1/6), considerando que se trata de quantidade expressiva de MDMA (versão melhorada do Ecstasy), com potencial de causar até morte, e LCD, alucinógeno com forte aptidão de debilitar os sentidos. Por isso, a reprimenda final é de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. Fixo o regime inicial fechado. As circunstâncias desfavoráveis apontadas (natureza; diversidade e significativa quantidade) demonstram maior lesividade concreta do delito e exigem um agravamento do regime inicial para que a pena seja suficiente para a reprovação e prevenção (art. 33, §3º, CP). Independentemente da quantidade da pena, tais circunstâncias subjetivas desfavoráveis também impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, III, CP) ou a concessão do benefício da suspensão condicional (art. 77, II, CP). Eventual detração penal (art. 387, §2º, CPP), se for o caso, deverá ser analisada pelo Juízo da Execução, único com competência para verificar a presença ou não dos requisitos subjetivos.

D) CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

- 1) ABSOLVER os réus CARINE LAIZE DE OLIVEIRA GRACIANO, GUILHERME MALAFAIA CUNHA e PRISCILLA MAIA CORREA DA SILVA, fazendo-o com amparo no art. 386, VII, do CPP; e
- 2) CONDENAR o réu EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS como incurso no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, na pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, regime inicial fechado, dias-multa fixados em 1/30 do salário mínimo.

Caso ainda não tenha sido feito, autorizo a devolução veículo apreendido ao seu proprietário. Comunique-se a Autoridade Policial.

Fica o réu condenado ao pagamento das custas (art. 804, CPP), observada eventual gratuidade concedida nos autos.

Expeça-se certidão de honorários, se for o caso, ficando a remuneração arbitrada em grau máximo.

Havendo interposição de recurso, intime-se a parte adversa para apresentação de contrarrazões e, oportunamente, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo, com nossas homenagens.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para destruição de eventual contraprova (art. 72, Lei 11.343/06) e comunique-se ao IIRGD e ao TRE.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Aruja, 21 de março de 2022.